

1500249-64.2022.8.26.0628
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER
Comarca: Itapecerica da Serra
Foro: Foro de Itapecerica da Serra
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 13/04/2022
... e decido.

Crime de roubo majorado
O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo:

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência às fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapecerica da Serra
Foro de Itapecerica da Serra
1ª Vara
Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500249-64.2022.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500249-64.2022.8.26.0628
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2032246/2022 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 22814490 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 398/22/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2032246 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
LEANDRO GOMES MIRANDA e outros
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra LEANDRO GOMES MIRANDA, imputando-lhe a conduta descrita no art. 157, § 2º, II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 28 da Lei n º 11.343/06, em concurso material.

Segundo a denúncia (fls. 67-68):

(1) No dia 03 de março de 2022, por volta das 20h00min, na Avenida XV de novembro, 4001, Centro, nesta cidade e comarca de Itapeçerica da Serra, o denunciado, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois agentes ainda não identificados, tentou subtrair, para si, o automóvel CHEVROLET/CELTA, placas FKT8978, pertencente à vítima Eliane Maria Galera, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 10/12 e auto de reconhecimento de fl. 13.

(2) Nas circunstâncias supra indicadas, o denunciado trazia consigo, para consumo pessoal, 03 (três) porções de cocaína, com peso líquido de 2.0g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14, laudo de constatação de fls. 18/20 e laudo químico-toxicológico a ser oportunamente acostado.

A denúncia foi recebida (fls. 69-71). Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 79-80.

Ratificado o recebimento da denúncia, em audiência de instrução e julgamento, ouviu-se a vítima e as testemunhas, sendo ao fim interrogado o réu.

O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. Em relação a dosimetria da pena, na primeira fase, pediu o reconhecimento dos maus antecedentes, na segunda fase a reincidência específica e confissão, e, na terceira fase, o concurso de agentes e tentativa no patamar mínimo de 1/3, uma vez que os roubadores conseguiram remover a vítima do veículo. Em relação ao art. 28, pediu a fixação da prestação de serviço comunitário pela reincidência.

A defesa, por sua vez, pediu o reconhecimento da primariedade técnica do acusado, o reconhecimento de sua confissão e a absolvição em relação ao art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Crime de roubo majorado

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo:

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência às fls. 10-12, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14, e pela prova oral colhida ao longo da instrução.

A autoria também está comprovada. Vejamos.

A vítima ELIANE MARIA GALERA disse, em juízo, que estava trabalhando no mercado Cercadão, quando saiu para o almoço e foi ao carro descansar. Contou que após uns 20 minutos no carro, mexendo no celular, chegaram 3 caras gritando “desce do carro”, um homem puxou-a pelo braço, tentou tirá-la do veículo, e outro rapaz chegou para ajudar. A vítima jogou os celulares no assoalho do automóvel, e os réus conseguiram a tirar do carro. Disse que saiu gritando e entrou no mercado, sendo que alguns funcionários do estabelecimento correram atrás dos homens e pegaram um deles, de camisa vermelha. Reiterou que a puxaram pelo braço, e que ficou com marcas de dedos e com manchas roxas no local. Asseverou que o homem que foi pego foi o que puxava a vítima para fora do carro, mandando descer. Fez reconhecimento na delegacia de polícia, mas já havia reconhecido ele no momento em que ele foi detido, não tendo qualquer dúvida. Ressaltou que o homem foi apreendido com simulacros de arma de fogo, mas que na hora do roubo não as tinha visto.

O guarda municipal ROBERTO ROGERIO DA SILVA disse em juízo que estava de plantão quando foi acionado para atender ocorrência. Quando chegou no local o indivíduo já estava contido, e foi encaminhado a delegacia junto com as testemunhas. No local os rapazes que o detiveram disseram que viram ele correndo com mais dois ou três

indivíduos e conseguiram alcançá-lo e detê-lo. Com ele foram encontradas algumas porções de cocaína. Não o conhecia. No momento, o réu negou os fatos.

O guarda municipal HIDELEBRANDO ROCHA PEREIRA disse em juízo que estava em patrulhamento quando foi comunicado da tentativa de roubo na avenida XV de Novembro. No local o preso já estava abordado por dois funcionários do supermercado. Ouviram dos rapazes que o abordaram que o réu tinha tentado subtrair um veículo com arma de brinquedo, mas que a vítima gritou e os funcionários do mercado conseguiram detê-lo. O réu disse no local que não havia sido ele, mas a vítima confirmou com certeza.

O réu LEANDRO GOMES MIRANDA, em juízo, confessou o delito. Disse que no dia dos fatos havia usado cocaína, conheceu um rapazes, esses meninos sugeriram tentar roubar um veículo, o réu concordou e anunciou o assalto, mandando a vítima sair do carro, mas ela reagiu, começou a gritar, fugiu para o supermercado e o réu tentou fugir, mas foi abordado por dois rapazes do supermercado. Os simulacros não eram seus. Disse estar arrependido.

Percebe-se, portanto, que a confissão do acusado encontra respaldo nos relatos da vítima e das testemunhas, não havendo qualquer controvérsia quanto à dinâmica dos fatos.

É certo que o réu, em concurso com outros agentes, tentou subtrair o veículo da vítima, mediante grave ameaça e violência, inclusive puxando-a pelos braços e ordenando que saísse do veículo.

Tal conduta, sem qualquer sombra de dúvidas, amolda-se com exatidão ao tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal.

Além disso, também se demonstrou a presença da causa de aumento presente no art. 157, §2º, inc. II, pois a vítima afirmou com certeza que o réu estava acompanhado de outras pessoas no momento da prática criminosa, fato que foi admitido pelo acusado.

Portanto, bem delineada a conduta típica, ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Crime do art. 28 da Lei 11.343/06

Assim dispõe o art. 28 da Lei 11.343/06:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

Respeitado entendimento contrário, que não se desconhece, ao ver deste juízo a referida criminalização é inconstitucional, por estabelecer injustificada e desproporcional restrição às liberdades individuais.

Dispõe o art. 5º, caput, da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...]

Evidentemente que, assim como os demais direitos e garantias constitucionais, a liberdade individual não é absoluta, podendo ser restringida pela lei, o que se justifica pela promoção do bem comum. Neste sentido, a lei deve estabelecer restrições à autonomia individual, de modo a impedir que o exercício desregrado da liberdade de um particular possa colocar em risco a sociedade que o cerca.

Por tais razões, o Direito Penal, que impõe as mais severas restrições às liberdades em nosso ordenamento jurídico, reserva-se somente para os casos em que haja repercussão social grave, não podendo ser acionado em situações nas quais a conduta lesa tão somente o próprio indivíduo, como no crime em análise, ao que se convencionou chamar de “princípio da alteridade”. Neste sentido, assim leciona Nilo Batista:

No direito penal, à conduta do sujeito autor do crime deve relacionar-se, como signo do outro sujeito, o bem jurídico (que era objeto da proteção penal e foi ofendido pelo crime – e por isso chamado de objeto jurídico do crime). Como ensina Roxin, “só pode ser castigado aquele comportamento que lesione direitos de outras pessoas e que não é simplesmente um comportamento pecaminoso ou imoral; (...) o direito penal só pode assegurar a ordem pacífica externa da sociedade, e além desse limite nem está legitimado e nem é adequado para a educação moral dos cidadãos.” À conduta puramente interna ou puramente individual – seja pecaminosa, imoral, escandalosa ou diferente – falta a lesividade que pode legitimar a intervenção penal.

[...]

No Brasil, o artigo 28 da Lei 11.343, de 23.ago.2006, incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais.

É, por tais razões, que o Direito Penal brasileiro não pune a embriaguez alcoólica, exceto quando relacionada à direção de veículo automotor, por colocar em risco a segurança dos demais motoristas e transeuntes (art. 306 do CTB). Também por isso, não se pune a autolesão, exceto quando efetuada com o intuito de fraudar seguro, por repercutir na esfera patrimonial de terceiros (art. 171, §2º, inc. V, do CP). Assim, fixadas tais premissas, forçoso convir que o porte de drogas para uso próprio diz respeito apenas ao usuário, não lesando bem jurídico de qualquer outra pessoa.

Não se nega, obviamente, os malefícios que os entorpecentes causam ao usuário, sejam os prejuízos à sua saúde como os prejuízos para sua vida social, muitas vezes decorrentes do vício. Ocorre que tais prejuízos também são observados diariamente no uso abusivo de tabaco ou álcool, por exemplo, sem que se cogite a criminalização de seu uso, justamente pelos motivos acima elencados.

Percebe-se, portanto, que não há razoabilidade na criminalização do porte para uso próprio de determinados entorpecentes e não de outros, havendo, em realidade, uma pretensão estatal de impor padrão de conduta moral supostamente majoritário, objetivo para o qual não se mostra proporcional ou adequada a utilização do Direito Penal.

Por tudo isso, entende-se que a criminalização do uso de drogas, ou do porte para o uso delas, configura restrição indevida da liberdade, com violação ao que dispõe o artigo 3º, IV, da Constituição Federal, dispositivo que veda todas as formas de discriminação.

Por fim, insta salientar que o Supremo Tribunal Federal já se debruça sobre o assunto, sendo que no julgamento do RE 635659 o relator Ministro Gilmar Mendes já votou pela inconstitucionalidade do referido tipo penal, tendo sido parcialmente acompanhado pelos Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, os quais restringiram a declaração de inconstitucionalidade à maconha por se tratar da droga objeto do caso concreto em julgamento naquela corte.

Pelo exposto, a absolvição do réu quanto ao crime de porte de drogas para uso próprio é medida que se impõe, ante a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06.

Considerando as diretrizes estabelecidas pelo artigo 68 do Código Penal, passo à individualização da pena imposta ao condenado em relação ao art. 157, §2º, inc II, do CP.

Primeira fase da dosimetria.

Nos termos do artigo 59 do CP, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie. Quanto à sua conduta social e a sua personalidade, entendo que não há

informações suficientes nos autos para as avaliar, devendo aqui ser valoradas as questões atinentes aos aspectos extrapenais do acusado. O motivo do crime é identificável como o desejo de obtenção de lucro, o que já é punido pelo tipo penal incriminador. As circunstâncias e consequências não se mostraram especialmente graves. Já o comportamento da vítima em nada contribuiu para os fatos.

Quanto aos antecedentes criminais, o réu possui quatro condenações com trânsito em julgado (processo 0011370-30.2008.8.26.0152, 0013785-15.2010.8.26.0152, 0016036-06.2010.8.26.0152 e 0003019-19.2018.8.26.0152 - fl. 112). Assim, no intuito de evitar o bis in idem, utilizarei as três primeiras condenações nesta fase, e a última condenação será avaliada como reincidência.

Portanto, considerando os maus antecedentes do réu, sendo ainda três condenações na presente fase, fixo a pena base 1/5 acima do mínimo previsto pelo legislador, fixando-a no momento em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Segunda fase da dosimetria

Presente a agravante genérica do artigo 61, inciso I do Código Penal, conforme já explicado, uma vez que o réu é reincidente.

Por outro lado, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. II, d, do CP).

Assim, compenso as circunstâncias e mantenho a pena nesta fase em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Terceira fase da dosimetria

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 157, §2º, inc. II, do CP, já que se provou que o roubo foi praticado em concurso de agentes. Assim sendo, aumento a pena em 1/3, estabelecendo-a em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Incide ainda a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, uma vez que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Considerando o iter criminis percorrido, isto é, que a vítima chegou a ser retirada a força do veículo e o réu, junto com seus comparsas, conseguiu entrar no automóvel, somente não fugindo pela rápida reação da ofendida, o crime por muito pouco não se consumou. Assim, a diminuição deve incidir no patamar mínimo previsto pelo legislador, qual seja, 1/3.

Assim sendo, fixo a pena definitivamente em 4 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Regime inicial

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP.

Detração (387, §2º do CP)

Levando-se em conta a reincidência do réu e o período de prisão preventiva cumprido até o momento, não é possível modificar o regime inicial ora fixado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do Código Penal):

Incabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos, já que o réu é reincidente em crime doloso e o delito foi praticado com violência e grave ameaça (art. 44, II, CP).

Pelo mesmo motivo, impossível a suspensão condicional da pena (art. 77, I e II, CP).

Fixação do valor do dia-multa (artigo 49, §1º, do CP)

Do que consta dos autos, o condenado não possui bens de valor, tampouco exerce profissão rendosa, motivos pelos quais fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (artigo 49, § 10, do Código Penal).

Diante do exposto, declaro inconstitucional o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, e, em consequência, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial para:

a) absolver o réu da imputação relativa ao art. 28 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

b) condenar o réu LEANDRO GOMES MIRANDA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 4 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo

legal, por infringência ao art. 157, § 2º, II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Considerando que o réu possui diversas condenações recentes, inclusive pelo crime de roubo, considero necessária a manutenção da prisão preventiva, como medida necessária para a garantia da ordem pública, em especial, para evitar a reiteração delituosa, nos termos do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal. Recomende-se.

Após o trânsito em julgado:

Proceda-se em relação as drogas apreendidas conforme o disposto no art. 72, LD, no que ainda couber.

Comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se o necessário.

Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do CPC, diante da gratuidade da justiça, que ora concedo.

Atendam-se às demais disposições do Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, no que for pertinente.

P.I.C.

Itapeccerica da Serra, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA